

1502098-44.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... conta com 19 anos. Já esteve preso por tráfico de drogas. Confessa os fatos. Praticou o delito, mas não deu nenhum tiro. A vítima que atirou. Estava com simulacro de arma de fogo. Não praticou o delito sozinho (primário com registros). Estava em liberdade provisória sob acusação de tráfico de drogas e receptação. Afirmou que Robert e Cauã não estavam em sua companhia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502098-44.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502098-44.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262323/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 20474251 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5031/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2262323 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Lemos Feitosa e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

FELIPE LEMOS FEITOSA, qualificado em fls. 04, ROBERT CAUÃ BERNARDES DE SOUZA, qualificado em fls. 12, VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado em fls. 13 e GABRIEL ARTILHEIRO ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado em fls. 14, foram denunciados e estão sendo processados como incursos na conduta descrita no artigo 157, parágrafo 3º, incisos II combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque,

no dia 24 de setembro 2021, por volta das 21h40min, na Rua André Passareli, altura do número 100, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, os acusados, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência exercida com o uso de arma de fogo, uma motocicleta Yamaha Fazer YS 250, placas DZQ2J45, de propriedade de Fábio Oliveira Moutinho, tendo, na ocasião, efetuado disparos de arma de fogo contra ele, não ocorrendo sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Recebida a denúncia (fls. 96/99, com ratificação em fls. 194/195), os réus foram devidamente citados e respostas à acusação (fls. 133/150, fls. 169/176 e fls. 188). No decorrer da instrução criminal, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Superada a fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a consequente condenação dos acusados nos exatos termos contidos na denúncia. As Defesas requereram a absolvição dos réus (fls. 268/269 e fls. 280/296) com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser parcialmente acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (18/19).

No que concerne à autoria, as imputações constantes da denúncia não foram comprovadas de forma cristalina em relação a todos os acusados, senão vejamos.

A vítima, FÁBIO OLIVEIRA MOUTINHO, relatou que conduzia sua motocicleta pela Rodovia Ayrton Senna e, quando reduziu a velocidade em um retorno, foi abordado por quatro indivíduos – dois deles com arma em punho – que anunciaram o assalto. Imediatamente, largou a motocicleta que veio a tombar no asfalto. Um dos indivíduos veio em sua direção para revistar o depoente que recuou e tentou sacar sua arma, momento em que os roubadores passaram a disparar contra o depoente que se jogou ao solo revidando os disparos. Efetuou quinze disparos na direção dos roubadores que deixaram o local correndo e atirando para trás.

Uma viatura passou pelo local. Pediu auxílio, noticiou os fatos com descrição das características físicas e vestimentas dos meliantes. Após algum tempo, sobre que três indivíduos haviam sido detidos. Reconheceu-os em solo policial como sendo roubadores da motocicleta. Na oportunidade, reconheceu o réu Vinícius fotograficamente. Não reconheceu nenhum dos réus em Juízo. Indicou o réu Robert em reconhecimento judicial, como sendo pessoa ligeiramente parecida, contudo, afirmou não estar certo de sua autoria. Ao ser exibido o réu Vinícius, afirmou que é a pessoa que reconheceu fotograficamente em solo policial em fotografia em que estava bem mais novo. É o acusado que fugiu do local.

VANDERSON RODRIGUES DA SILVA, policial militar, relatou ter tido notícia via COPOM de que um policial militar havia sido vítima do roubo de sua motocicleta Fábio havia sido submetida a uma tentativa de roubo de sua motocicleta e reagiu disparando sua pistola com os roubadores, contudo, não os atingiu. A motocicleta não foi levada. De posse das características dos indivíduos, passaram a efetuar patrulhamento com vistas a localizar os suspeitos. Em determinado momento, nas proximidades de local, viram o momento em que um indivíduo saiu do interior de uma matagal, apavorado, coração acelerado e transpirando. Indagado, o indivíduo acabou confessando o roubo e acabou levando o depoente e seus colegas de trabalho na casa de seus comparsas: Gabriel e Robert. Gabriel, de sua vez, chegou a indicar um quarto indivíduo, contudo, não foi localizado, mas a genitora dele entregou o documento de seu filho aos policiais. Tratava-se do réu Vinícius. Foi apreendido um

simulacro de arma de fogo. Confirmou os relatos prestados em solo policial no sentido de que a vítima do roubo reagiu ao delito "descarregando" sua arma. Disse, ainda, que os relatos que prestou na delegacia decorrem dos relatos da própria vítima, já que não presenciou os fatos. Não tem conhecimento de realização de perícia no local dos fatos.

Seu colega de trabalho, RODRIGO EDUARDO TOLEDO, corroborou os relatos por ele apresentados. Chegaram ao local após o ocorrido. Receberam a informação de tentativa de roubo. Afirmou ter tido a informação que a vítima, policial militar, - ao reagir a um roubo - chegou a descarregar a arma nos réus, contudo, não atingiu nenhum deles. O local não tem iluminação e é cercado por área de mata sendo retorno de rodovia. Não foi possível localizar projéteis de arma de fogo. O policial disse que mais e um indivíduo aparentava estar armado. Felipe confessou os fatos assim como Gabriel e Robert. Não soube dizer se foi realizado exame residuográfico nas mãos dos réus.

Foram arroladas testemunhas arroladas pela Defesa dos réus Gabriel e Robert.

ANDREZZA IGNES DOS SANTOS disse que é nora de Gabriel e do réu Robert Cauã. Ambos namoram suas filhas. Os réus foram presos no interior de sua residência. Moram na mesma residência que a testemunha. Na data dos fatos, o réus haviam sido antes para comprarem ingredientes para um bolo. A polícia invadiu sua casa e os levou. Nada de ilícito foi encontrado no interior de sua casa. Ambos os rapazes tem trabalho.

Os réus foram interrogados.

FELIPE LEMOS FEITOSA conta com 19 anos. Já esteve preso por tráfico de drogas. Confessa os fatos. Praticou o delito, mas não deu nenhum tiro. A vítima que atirou. Estava com simulacro de arma de fogo. Não praticou o delito sozinho (primário com registros). Estava em liberdade provisória sob acusação de tráfico de drogas e receptação. Afirmou que Robert e Cauã não estavam em sua companhia.

ROBERT CAUÃ BERNARDES DE SOUZA conta com 19 anos. Nunca foi preso. Nega os fatos. Foi preso no interior da residência de sua sogra. Invadiram a casa e o algemaram. Trabalha no lava-rápido do seu pai.

GABRIEL ARTILHEIRO ALMEIDA DOS SANTOS conta com 18 anos. Não sabe dizer porque foi preso. A polícia chegou e o levou juntamente com Robert na casa da sua namorada. Trabalha como garçom e serviços gerais no Bar do Peixe.

VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA conta com 22 anos. Nunca foi preso. Chegaram em sua casa e disseram que pegaram seu R.G. na casa de sua ex mulher. Foram até a casa de sua mãe, mas não estava lá. Estava com seu ex-patrão tomando uma cerveja.

Passo à análise de prova.

De saída, antes mesmo da análise de autoria, há que registrar não haver prova nos autos acerca dos disparos de arma de fogo por parte dos agentes que tentaram subtrair a motocicleta.

Não se está colocando desqualificando o relato da vítima, contudo, a questão é dúbia já que há somente seu relato nos autos acerca de ocorrência de troca de tiros entre esta e os roubadores. Não houve testemunhas presenciais e não foi feita qualquer perícia no local de forma a registrar cápsulas de armamentos diversos, tampouco, exame residuográfico nas mãos dos indivíduos presos naquela data.

A arma apreendida é do policial militar e o outro objeto que consta do auto de apreensão acostado aos autos se trata de um simulacro de arma de fogo.

Por fim, os relatos dos policiais militares ouvidos nos autos são paradoxais, já que em mesma oportunidade, afirmaram versões diversas e dotadas de dúvida por eles mesmo declaradas acerca da efetiva troca de tiros ou não.

Inicialmente, afirmaram terem tido notícia via COPOM de roubo tendo como vítima policial militar que tivesse reagido com disparos de arma de fogo quando da abordagem. Em seguida, afirmaram que se tratou de revide, contudo, todos os relatos decorriam da versão da vítima, já que nada presenciaram.

Os roubadores não conseguiram arrebataram o bem almejado da posse da vítima, de sorte que o delito não se consumou.

Tendo em vista o concurso de agentes, o não arrebatamento da res e a apreensão tão somente de simulacro de arma de fogo, é dos autos que o fato ocorrido encontra perfeita subsunção à conduta descrita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

No que atine à autoria, somente há certeza em relação ao réu Felipe.

Em solo policial, a vítima reconheceu os réus Felipe, Gabriel e Robert pessoalmente. A despeito disso, tais reconhecimentos não foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Entretanto, o réu Felipe confessou os fatos e a prova dos autos, a despeito do não reconhecimento da vítima corrobora sua confissão. Isto porque o réu foi surpreendido por policiais militares nas proximidades do local após sair do interior de área de matagal ofegante, transpirando e muito assustado. Teria confessado os fatos e indicado os demais réus como autores do delito.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência existente em favor do réu Felipe sendo este autor de roubo simples praticado em concurso de agentes na forma tentada.

O mesmo não se dá em relação aos demais acusados.

Os réus Robert e Gabriel foram presos na mesma ocasião. Estavam no interior de suas residências e nada de ilícito foi com eles encontrado. A vítima não os reconheceu em Juízo. Indicou o réu Robert como pessoa ligeiramente parecida a um dos roubadores. No entanto, levando-se em conta a ausência de situação de flagrância e o fato de nada de ilícito ter sido encontrado no momento da prisão dos réus, impossível ter-se Robert como autor do delito tão somente por similaridade e, ainda dúvida, em relação ao roubador. Os acusados devem, portanto, ser absolvidos.

Em relação ao réu Vinícius, afirmaram os policiais militares que estiveram na casa do acusado e pegaram o documento de identificação do tipo R.G. através de contato com a genitora do réu. Em solo policial, a vítima, vendo tal documento, indicou Vinícius como sendo um dos roubadores. Em Juízo, afirmou: "este é aquele que eu reconheci na fotografia do R.G., na delegacia."

Não indicou a vítima qualquer descrição física acerca de tal acusado, tampouco, o comportamento que tivesse desenvolvido durante a cena delitiva. Não houve prisão em flagrante, o acusado respondeu à ação penal em liberdade sem obstar a aplicação da lei. Nenhum elemento de convicção dos autos indica o réu Vinícius como autor do delito.

É sabido que o reconhecimento fotográfico não tem qualquer validade, já que não ocorreu como preceituado pelo artigo 226, do Código de Processo Penal.

Assim tem se manifestado nossa jurisprudência.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento da vítima em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a vítima "disse não ter convicção para efetuar o reconhecimento do réu" (e-STJ, fl. 188). 3. Agravo regimental não provido. (STJ Agravo Regimental no Resp nº 1914998 - SP 2- 021/0004018-6 - 5ª Turma - Relator Min. Ribeiro Dantas).

Ainda:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 Documento: 2048532 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/05/2021 Página 1de 4 Superior Tribunal de Justiça do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou

presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento Documento: 2048532 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/05/2021.

7. (...)

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente. (STJ - Habeas Corpus nº 652.284 - SC (2021/0076934-3 - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma).

Trata-se de entendimento pacificado pela jurisprudência, o que diante do vago contexto probatório e da forma como se processou tal reconhecimento, seja em solo policial, seja em solo judicial, o pedido é também improcedente em relação ao réu Vinícius, devendo este ser absolvido.

Passo à dosagem da pena.

Analisando as circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal verifico que a conduta é similar a outras ocorridas de sorte que permanece o reprovabilidade estipulado pelo legislador. Além disso, é sabido que ações penais em curso não podem servir para exasperação da pena como enunciado pela súmula 444, do Supremo Tribunal Federal. Assim, fixo apenas a base no mínimo legal de reclusão pelo período de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes. O réu é menor de 21 anos e confessou os fatos, contudo, ante a fixação a pena-base no mínimo legal, incabível diminuição da pena ante o enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o concurso de agentes na prática delitiva, majoro a pena em 1/3, na forma do parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, o que resulta em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante a não consumação do delito e considerando o iter criminis desenvolvido diminuo a pena em 2/3, o que resulta em reclusão pelo período de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e 4 (quatro) dias-multa, a que torno concreta ante o esgotamento de circunstâncias a serem valoradas na cominação da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Incabível substituição na forma do artigo 44, do Código Penal, por expressa vedação legal.

Estabeleço o dia-multa no mínimo legal vez que inexistem nos autos circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO FELIPE LEMOS FEITOSA ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de reclusão pelo período de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias e pagamento de 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto, como incurso na conduta prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. ABSOLVO os réus ROBERT CAUÂ BERNARDES DE SOUZA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA e GABRIEL ARTILHEIRO ALMEIDA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em relação a todos os réus.

Transitada em julgado esta, expeçam-se guias de recolhimento definitivas e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA